

1500095-36.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... já conhecido pela polícia como ponto de tráfico, havia dois indivíduos na prática do narcotráfico, descrevendo-os como sendo um branco, sem camisa, trajando bermuda estampada, enquanto o outro era negro e trajava bermuda azul e camisa vermelha. Diante disso, foram até o local informado e lá avistaram dois indivíduos com características idênticas às que foram passadas pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500095-36.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2012469/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 22439916 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 126/22/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2012469 - 02º D.P. PIRACICABA, 126/22/922 - 02º D.P. PIRACICABA, 2012469/2022 - 02º D.P. PIRACICABA

PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO OLIVEIRA SOUZA

Réu Preso

Contr. nº 2022/000062

Aos 04 de abril de 2022, às 13:30 horas, por meio de audiência virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Antonio Carlos Perez Antunes da Silva foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu DIEGO OLIVEIRA SOUZA (PRESO CDP local). Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PMS Flavio Zanoni Junior e WANDERSON ELIAS RAMOS DA COSTA AZEVEDO.

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

Pela M.M Juíza de Direito foi explicado que conforme artigo 8º do provimento CSM nº 2651/22, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça.

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não

terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (PMs Wanderson e PM Flávio) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a).DIEGO OLIVEIRA SOUZA, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 16h50, na Rua Carlos Sandalo, 313, Monte Líbano, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, guardava, para fins de tráfico, 8,1g de cocaína em pó, distribuídos em 27 microtubos e 3g de cocaína em pedra, distribuídos em 25 invólucros, substâncias entorpecentes as quais determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (fls. 67/70). O réu foi notificado, a denúncia foi recebida e durante a instrução prestaram depoimento as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o réu interrogado. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade delitativa foi confirmada nos autos pelo auto de exibição e apreensão a fl. 12/13, foto a fl. 14 e laudo pericial a fls. 77/79. Da mesma forma, comprovada a autoria delitativa. De fato, o policial relatou, na fase informativa (fls. 02), que "estava em patrulhamento junto de seu parceiro de farda pelo bairro Parque Eucaliptos, quando receberam informações de um transeunte, o qual não quis se identificar, informando que pela Rua Carlos Sândalo no cruzamento com a Av. Thales Castanho de Andrade havia dois indivíduos na prática de tráfico de drogas, sendo um indivíduo branco de bermuda estampada e o outro preto de bermuda azul e camisa vermelha. Mediante isso, deslocaram-se até o local informado, momento em que avistaram dois indivíduos, com características idênticas àquelas passadas na denúncia, que ao notarem a presença da equipe, tentaram adentrar em uma residência, sendo abordados de pronto. Os indivíduos foram identificados como sendo DIEGO OLIVEIRA SOUZA e MICHAEL DOUGLAS DEALMEIDA FORTUNATO. Relata que próximo aos indivíduos foi localizada uma bolsa pequena de tecido, contendo 27 eppendorfs de substância análoga à cocaína, 25 pedras de substância análoga à crack, bem como a quantia de R\$ 204,35 (duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos) em dinheiro. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ambos. Questionados, se mantiveram em silêncio em relação a propriedade do dinheiro e da droga. Com isso, ambos foram conduzidos até este Plantão Policial, havendo a necessidade do uso de algemas, tendo em vista o fundado receio de fuga, e nesta sede, ao serem questionados novamente, DIEGO assumiu a posse dos entorpecentes e do dinheiro que estavam na bolsa de tecido". Em juízo confirmou sua versão. Acrescentou que ele assumiu na minha frente, na frente de meu companheiro de farda e na presença do delegado. Ele falou na ocasião "o seu trabalho é procurar e o nosso é tentar dificultar o trabalho de vocês." O entorpecente foi encontrado na parte de fora da casa ao lado do réu e da outra pessoa que ali estava. Recebeu denúncia do COPOM e de um transeunte. Ela fazia referência a 2 indivíduos. Os 2 indivíduos tentaram entrar rapidamente na residência e foram abordados. As drogas estavam em uma sacola próxima a eles. O seu companheiro de farda corroborou as informações prestadas. Assim, a grande quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, juntamente com a apreensão de dinheiro, somadas às circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam o comércio ilícito. De fato, havia informações de que o réu e outro indivíduo estavam traficando. Nas proximidades deles foram encontrados dinheiro e drogas. Como se bastasse isso, informalmente Diego confessou a prática delitativa e, em Juízo, assumiu que assim agiu. O Michael e o réu, pelo que lhe informaram, moravam no imóvel. Neste panorama, devidamente demonstradas materialidade e autoria delitivas. Diante do acima exposto, requer-se a procedência

da ação, condenando-se o réu nos termos da incoativa. Na aplicação da pena há que se observar que o réu é reincidente específico (conforme certidão constante a fls. 32/34), razão pela qual se dedica a atividades criminosas e não faz jus à causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Outrossim, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, de acordo com as normas legais, e porque o crime de tráfico merece um grau maior de reprovabilidade, pois causa sérias consequências no meio social, notadamente no meio familiar, fomentando o uso indiscriminado de entorpecentes e, consequentemente, a prática de outros crimes pelo usuário, como pequenos furtos e roubos, os quais são praticados com o escopo de sustentar o seu vício. Incabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que reconhecida a impossibilidade de ser aplicado o redutor pelas razões antes mencionadas, a pena suplantará 04 anos, bem como o crime em questão é de elevada gravidade, o que demonstra não ser a medida socialmente adequada. Por fim, uma vez que comprovado que o dinheiro apreendido era oriundo do comércio de drogas, o Órgão Ministerial requer que seja decretada sua perda.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). DIEGO OLIVEIRA SOUZA foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme os fatos narrados na inicial acusatória. Recebida a denúncia, o feito teve seu regular trâmite, sendo encerrada a instrução na presente audiência. O Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Ocorre, contudo, que a ação penal deve ser julgada improcedente. Excelência, inicialmente é preciso reconhecer que não há provas que permitam concluir, com segurança, que o réu incorreu no crime de tráfico de entorpecentes que lhe foi atribuído. Isso porque a incriminá-lo só há o depoimento dos policiais militares, responsáveis por sua prisão (Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo e Flavio Zanoni Junior). Na fase policial, ambos disseram que estiveram no local dos fatos em razão de denúncia anônima que noticiava a prática de tráfico de drogas por dois indivíduos, um branco trajando bermuda estampada e o outro de cor preta, de bermuda azul e camisa vermelha. Quando ali chegaram, esses dois indivíduos – um deles o réu – demonstraram nervosismo e tentaram ingressar em uma residência, porém foram abordados de pronto. Próximo a eles acabaram localizando uma bolsa de tecido contendo as substâncias entorpecentes descritas na denúncia, porém nenhum deles trazia nada de ilícito junto ao corpo. A princípio, segundo os policiais, os dois indivíduos se mantiveram silentes, mas no plantão policial, o réu acabou assumindo a propriedade das drogas. Judicialmente, os policiais trouxeram narrativa idêntica. Wanderson acrescentou que não chegou a ver ninguém dispensando a droga e que apenas na delegacia Diego admitiu a propriedade, afirmando que era função dele “dificultar” o trabalho dos policiais. Flavio Zanoni, por sua vez, confirmou que só identificaram a propriedade da bolsa em razão da confissão informal de Diego. Ou seja, como se nota, durante a persecução penal só foram ouvidos os responsáveis pela captura do réu, que, evidentemente, são testemunhas parciais. Afinal, não há como negar que os depoimentos dos policiais militares estão contaminados pela atuação que tiveram na apuração dos fatos, o que gera a necessidade de justificar os atos praticados. Assim, ainda que não estejam impedidos de depor, certo é que seus testemunhos devem ser recebidos com cautela, sobretudo no momento de se conferir o devido valor probatório. Não é por outra razão que em diversas ocasiões já se decidiu pela impossibilidade de se fundamentar uma condenação apenas com base na palavra dos responsáveis pela persecução penal: “As palavras dos policiais merecem credibilidade, mas não basta o título (exercício da função de policial). Há necessidade de que estas tenham apoio em evidências circunstanciais e testemunhais, sob pena de exaltar-se um registro indiciário como absoluto, infalível e inquestionável”. (TJSP - 7ª Câ. - Ap. Cr. n. 1.465.651/6 - Com. de Campinas - j. 19/5/2005 - v.u.). No mesmo trilho ensina o professor Gustavo Henrique Badaró (os destaques são nossos): “Quanto aos depoimentos dos policiais, há correntes radicais, que, pelo seu próprio extremismo, devem ser descartadas. Uma dessas correntes entende que o fato de a testemunha ser policial, por si só, não a torna impedida de depor, não havendo qualquer disposição legal neste sentido. Ao contrário, o policial não se enquadra nas hipóteses do art. 207 do CPP, devendo ser

dado ao seu depoimento o mesmo valor de qualquer outra testemunha. De outro lado, há corrente oposta, no sentido de que os policiais, pela simples condição funcional, seriam suspeitos. Deve prevalecer uma corrente intermediária: se os policiais não podem ser considerados suspeitos, pelo simples fato de serem policiais, por outro lado, é inegável o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos investigatórios praticados, pelo que seus depoimentos têm valor relativo, devendo ser cotejados com outros elementos de provas existentes nos autos, em especial o testemunho de pessoas estranha aos quadros da polícia. Não se pode esquecer que as testemunhas são, por definição, terceiros imparciais, sem qualquer interesse no processo, o que não é exatamente o caso dos policiais em relação aos crimes por eles investigados. Por tais motivos, não se deve admitir que seja proferida uma sentença condenatória com base exclusiva no depoimento de policiais, ainda que estes se mostrem harmônicos entre si". (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 8ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 588). E, no caso sob análise, para além dos depoimentos dos agentes integrantes aos quadros da segurança pública, nenhuma outra prova foi produzida. Na verdade, observa-se que o acusado não tinha nenhuma substância ilícita ou, mesmo, objeto ilícito em seu poder. Além disso, também havia um outro suspeito, que acabou liberado. Nessas circunstâncias, não há como dizer se as substâncias pertenciam ao réu ou ao outro sujeito. Há apenas uma confissão informal nesse sentido, mas tal elemento não se reveste de nenhum valor probatório, posto que não é crível que a pessoa queria se autoincriminar perante os policiais militares e, depois, perante delegado de polícia e autoridade judiciária, apresente outra versão. E se, de fato, houve alguma confissão informal, ela deve ser desprezada, uma vez que evidentemente foi obtida sem qualquer observância às garantias constitucionais que a pessoa acusada possui, sobretudo o direito ao silêncio. Assim, as provas produzidas contra o réu são bem precárias, ainda mais considerando o crime que lhe é atribuído, equiparado a hediondo. Não se quer dizer que os policiais mentiram, mas apenas que, para a condenação, prova mais robusta é necessária. A propósito, cumpre registrar que quanto mais se dá crédito a esse tipo de prova, mais se incentiva a precariedade de investigações, o que pode dar azo a abusos e manipulações. Dessa forma, por tudo que foi exposto, sendo frágil o conjunto probatório, a Defesa requer a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Todavia, caso o entendimento de Vossa Excelência seja diverso, em caso de condenação pelo crime mais grave narrado na denúncia, requer-se a fixação da pena no mínimo legal, considerando que não houve apreensão significativa de entorpecente. Em seu favor há atenuante da confissão. Também é o caso de aplicação da causa redutora de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, inobstante a condição de reincidente do réu (a condenação anterior que registra é pela prática de furto). Isso porque essa circunstância será considerada para agravar a pena do réu na segunda etapa. Assim, sua utilização para negar a diminuição da pena acaba constituindo bis in idem, não autorizado pelo ordenamento jurídico, que rechaça a possibilidade da mesma circunstância ser utilizada por mais de uma vez para agravar a situação do agente. Além disso, o STJ já decidiu que a reincidência, por si só, não afasta o "tráfico privilegiado": "A ínfima quantidade da droga apreendida não justifica o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo perfeitamente cabível a sua aplicação em patamar intermediário (1/2), diante da reincidência" (HC 660.930/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021). Dessa forma, nada impede que seja reduzida a pena do réu, ainda que não seja no patamar máximo. E com o reconhecimento da causa especial de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, mostra-se possível, por consequência, a fixação de regime inicial diverso do fechado. Por fim, tendo em vista o princípio da presunção de inocência, requer-se seja conferido ao acusado o direito de apresentar eventual apelação em liberdade.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos.

DIEGO OLIVEIRA SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque,

segundo a denúncia, no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 16h50, na Rua Carlos Sandalo, 313, Monte Líbano, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, guardava, para fins de tráfico, 8,1g de cocaína em pó, distribuídos em 27 microtubos, e 3g de cocaína em pedra, distribuídos em 25 invólucros, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro acima mencionado, quando receberam a descrição de indivíduo que estaria praticando o tráfico ilícito de entorpecentes no endereço supramencionado. Em razão disso, para lá se dirigiram e visualizaram o acusado, o qual tinha as mesmas características informadas e, ao perceber a aproximação da viatura, tentou entrar em uma residência, mas foi abordado. Em busca pessoal, nada foi localizado. Porém, nas proximidades da abordagem, os policiais encontraram e apreenderam uma bolsa de pano, na qual estavam as drogas acima mencionadas, bem como a quantia de R\$ 204,35, produto do narcotráfico.

Conclui a a denúncia que todas as drogas encontradas pertenciam ao acusado e se destinavam ao comércio.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 91). Defesa preliminar apresentada às fls. 94/95. Após, a denúncia foi recebida (fls. 97) e o réu foi citado às fls. 126.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade do delito.

A Defesa pediu a absolvição, por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) boletim de ocorrência de fls. 09/11;
 - 2) auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e fotografia de fls. 14;
 - 3) laudo de constatação de fls. 16/18 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 77/79, com resultado positivo para cocaína em relação às substâncias apreendidas;
- A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 08), o réu exerceu o direito de permanecer em silêncio. Interrogado em juízo (gravação), negou o crime. Disse que foi abordado dentro de uma casa situada no local dos fatos, onde estava residindo com a esposa há dois dias. Alegou que antes dos fatos, trabalhava como servente de pedreiro dentro de condomínio. Como estava há dois dias sem receber o salário, procurou um barraco para morar com a mulher. Combinou com Michael, o responsável pelo imóvel, que poderia pagar o aluguel depois que recebesse o salário. Foi abordado junto com ele dentro da casa. Assumiu a propriedade das drogas porque foi induzido por Michael. Disse saber que Michael tinha envolvimento com o tráfico, mas não sabia que na casa havia drogas, fato que só descobriu quando os policiais encontraram a bolsinha com os entorpecentes.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 03) e sob o crivo do contraditório (gravação), o policial militar Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo declarou que, no dia dos fatos, ele e seu colega de farda realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro quando receberam notícia de um transeunte que não quis se identificar, de que, no cruzamento da Rua Carlos Sândalo com a Av. Thales Castanho de Andrade, local já conhecido pela polícia como ponto de tráfico, havia dois indivíduos na prática do narcotráfico, descrevendo-os como sendo um branco, sem camisa, trajando bermuda estampada, enquanto o outro era negro e trajava bermuda azul e camisa vermelha. Diante disso, foram até o local informado e lá avistaram dois indivíduos com características idênticas às que foram passadas pelo denunciante. Esclareceu que, ao notarem a presença da equipe policial, os dois tentaram entrar numa

residência que havia ali, mas conseguiram abordá-los. Ambos foram identificados, um deles como sendo o réu Diego e o outro como sendo Michael Douglas de Almeida Fortunato. Próximo de onde estavam postados inicialmente foi localizada uma bolsa pequena de tecido contendo 27 eppendorfs de cocaína e 25 pedras de crack, além da quantia de R\$ 204,35 (duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos) em dinheiro. Submetidos a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles. Apuraram que Michael era o responsável pela residência e fizeram uma busca ali com autorização dele, mas nada de ilícito foi encontrado em seu interior. Questionados sobre a droga e o dinheiro, ambos negaram a posse. Entretanto, quando chegaram na delegacia, o réu Diego assumiu ser o dono dos entorpecentes e do dinheiro apreendido, fazendo, inclusive, uma brincadeira ao dizer "você fazem a sua parte, que é procurar droga, e nós fazemos a nossa, que é dificultar a ação da polícia", declarações que fez perante ele, seu parceiro e a Autoridade Policial. Por fim, disse que não conhecia o réu anteriormente.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 05) e em juízo (gravação) pelo policial militar Flávio Zanoni Junior.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a

credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido.” (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO – j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS – j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR – j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO – j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR – j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra de agente público: enquanto o interesse deste é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos policiais militares não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu possuía os entorpecentes descritos na denúncia, para fins de mercancia.

Sua negativa em juízo foi afastada pelos uníssonos e convergentes depoimentos dos policiais militares no sentido de que, ao notarem a presença da viatura policial no local, o réu e o outro indivíduo (Michael), que estavam juntos postados no ponto de tráfico ali existente, agiram de forma suspeita, tentando adentrar rapidamente uma residência, mas acabaram sendo abordados e, próximo de onde estavam postados, foi localizada a bolsa pequena contendo os entorpecentes e considerável quantia em dinheiro (R\$204,35), cuja origem lícita não foi comprovada.

Em que pese a negativa judicial, quando chegou na delegacia, o réu confessou informalmente aos policiais que as drogas lhe pertenciam e ainda chegou a fazer uma brincadeira com eles, ao dizer que “vocês fazem a sua parte, que é procurar droga, e nós fazemos a nossa, que é dificultar a ação da polícia”, palavras essas que são totalmente incompatíveis com quem teria feito a confissão de forma forçada ou influenciado pelo colega Michel, como alegou o réu.

A existência de denúncia anônima precedente à diligência, indicando que o tráfico era exercido no local por duas pessoas e que o réu, um dos que ali estava postado, tinha as exatas características informadas de um dos traficantes, corrobora a convicção de que as drogas lhe pertenciam.

Comprovadas, dessa forma, a autoria delitiva, a materialidade e o destino mercantil das drogas apreendidas, destino este que se reforça com a existência de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, incompatíveis com a situação de mero usuário.

Some-se a tudo isso o fato de as drogas estarem fracionadas e acondicionadas em porções individuais, como comumente são comercializadas (fotografia de fl. 14). Além disso, junto delas havia expressiva quantia em dinheiro (R\$204,35), o que, aliado à falta de comprovação idônea por parte da Defesa, da origem lícita, faz presumir decorrer do comércio ilegal e confirma o destino mercantil dos entorpecentes, ensejando, inclusive, seu perdimento para a União.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO." (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

"MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvção - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, ficando afastada a tese defensiva de insuficiência probatória.

Passo à individualização das penas.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

A existência de diversidade de drogas e a quantidade, embora mais expressiva a ponto de indicar o tráfico, não fugiram à normalidade da espécie.

Assim, fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão da autotir do crime (a confissão informal foi considerada como um dos elementos de convicção).

Por outro lado, reconheço a agravante da reincidência específica (certidão de fls. 33: proc. 1500484-60.2018, da 2ª Vara da Comarca de São Pedro, com trânsito em julgado para a defesa aos 08/09/2020).

Como ambas as circunstâncias se compensam, deixo de aumentar ou diminuir as penas na segunda fase.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de penas.

Registro que a reincidência, que, inclusive, é específica, impede a aplicação do redutor do parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06 e impõe a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis (também incabíveis em razão da quantidade de pena aplicada), pois indica que o réu vem reiterando na prática do crime em questão.

Acrescente-se a isso as graves consequências do delito de tráfico, que fomenta a prática de vários outros crimes, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que dificilmente conseguem se livrar do vício.

Não bastasse, a espécie de uma das drogas que o réu comercializava ("crack") é considerada mais nociva ao ser humano, causando grande dependência e destruindo famílias e vidas.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seu grave ato.

Há várias decisões de nossos Tribunais no sentido de que é possível a eleição do regime fechado, sem substituição por restritivas de direitos, no crime de tráfico de drogas se a natureza, a reincidência e as circunstâncias concretas do crime indicarem tratar-se de agente de maior periculosidade.

Confira-se julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso da defesa – Absolvição por falta de provas – Improcedência – Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares bastam para a comprovação da mercancia ilícita – Tráfico bem caracterizado – Condenação mantida – Penas bem dosadas – Regime inicial fechado bem imposto, diante da gravidade concreta da infração penal e da reincidência específica do réu – Recurso defensivo improvido." (TJSP - Apelação 0037058-28.2016.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017)

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Apreensão de 200g de cocaína e um revólver calibre 32. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Incabível a absolvição ou desclassificação. Materialidade e autoria indúvidas. Réu detido na posse de chave de veículo automotor, em cujo interior foram encontradas a arma e as drogas. Ausência de justificativa plausível acerca dos fatos. Forma de acondicionamento do entorpecente aponta a traficância. Porte de arma e munições é delito de perigo abstrato. Arma periciada. Potencialidade lesiva atestada. Dosimetria bem realizada. Reincidência impede a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos. Regime fechado decorre do quantum da pena e da biografia penal do acusado, além da gravidade, consequências e hediondez do crime. Recurso não provido". (TJSP - Apelação 0003463-89.2015.8.26.0400. 8ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator(a): Carlos Monnerat - j. 05/09/2017) -g.n.

Registro que o reconhecimento da reincidência para fins de impedir a concessão de benefícios ao acusado e apená-lo de forma mais grave não fere a coisa julgada, nem constitui "bis in idem", pois não se trata de punir o agente duas vezes pelo mesmo fato.

Como bem ensina Guilherme de Souza Nucci, essa ideia "peca pela simplicidade. O sistema de fixação de penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF)" (CPComentado - RT, 13ª ed., pag. 464).

Ao se reconhecer a reincidência e aumentar a pena do crime em razão dessa agravante ou deixar de aplicar ao réu alguma benesse, o Estado nada mais faz do que punir com maior rigor o agente que, tornando a delinquir, desafia a ordem pública e as leis vigentes, demonstrando, no dizer do professor Nucci, "persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade. Destarte, sofre uma punição

mais severa" (obra citada, pag. 464).

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico.

APELAÇÃO CRIMINAL - PENA E REGIME PRISIONAL - Pena fixada com critério e corretamente - Reincidência do réu que inviabiliza a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas - Bis in idem não caracterizado, pois o aumento na segunda etapa e a impossibilidade de aplicação do privilégio na terceira fase são efeitos distintos decorrentes do mesmo instituto - Inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, por força do disposto nos artigos 44, incisos I e II, e 77, caput, e inciso I, ambos do CP - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso desprovido." (TJSP - Apelação 0003941-43.2015.8.26.0127 - 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Nelson Fonseca Junior - j. 14/09/2017) -g.n.

Anoto que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o réu está preso há apenas dois meses e vinte e dois dias, não tendo, ainda, preenchido o requisito objeto para progressão de regime.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu DIEGO OLIVEIRA SOUZA a cumprir cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado que a quantia apreendida (R\$204,35) é decorrente do tráfico, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Conforme acima exposto, o réu é reincidente específico, o que indica real possibilidade de reiteração criminosa.

Assim, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual é necessária para garantia da ordem pública e fica, assim, mantida.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido, servindo-se a presente de ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença ora proferida. Pelo RÉU e DEFESA foi dito que DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA da acusação ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data para o MP.

Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação. Regularize-se o sistema informatizado. Juntadas as razões, vista ao MP para contrarrazões de recurso. Expeça-se guia de recolhimento e internamento provisória, se o caso. Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.